

1500618-79.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500618-79.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500618-79.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2175137/2022 - 1º Distrito Policial de Lorena, 25821819 - 1º Distrito Policial de Lorena, 2175137 - 01º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE LUIZ LUCIANO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JOSÉ LUIZ LUCIANO, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, artigo 12, caput, e 16, caput, ambos da Lei 10.826/03 (fls. 57/58).

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado, apresentando defesa prévia (fls. 80/91). Na sequência, a peça acusatória foi recebida em 18 de julho de 2022 (fls. 75/79).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas, e realizado o interrogatório do réu. Em seguida, o Ministério Público apresentou as suas alegações finais em audiência (mídia às fls. 142/143) e a defesa, por meio de memoriais escritos.

O Parquet requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu

pelos delitos dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 16, caput, da Lei 10.826/03, absorvendo-se o crime do artigo 12, da Lei 10.826/03.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado. Em preliminar, suscitou a nulidade das provas, por violação à garantia constitucional do réu.

Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu o reconhecimento da figura privilegiada do tipo; a aplicação do princípio da insignificância, em relação ao delito da Lei de Armas; a fixação das penas no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão; e o estabelecimento do regime inicial menos severo (fls. 144/154).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Afasto a preliminar defensivo.

No caso em apreço, a ação policial observou os limites traçados pela Constituição Federal.

Como se verá à frente, a entrada dos policiais militares no imóvel foi precedida pela autorização do próprio acusado que, surpreendido na via pública, em frente a sua casa na posse de entorpecentes, confessou àqueles que guardava mais drogas em seu imóvel.

De todo modo, convém esclarecer que o comportamento suspeito do acusado, que tentou correr para o interior do imóvel ao avistar os policiais militares, por si só, já justificava o ingresso dos policiais na residência.

Frise-se que a própria norma constitucional que garante a inviolabilidade domiciliar (artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal) expressamente excepciona o estado flagrancial, mostrando-se perfeitamente legítimo o agir dos agentes públicos na espécie.

Insta salientar que o próprio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), estabeleceu as diretrizes para o controle judicial em tais hipótese, firmando a seguinte tese:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

Portanto, fácil concluir que a conduta dos agentes públicos estava amparada pela existência de fundadas razões (justa causa), diante do agir do réu.

A propósito, em caso semelhante e recente:

“APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS Preliminar - Alegação de nulidade decorrente de invasão de domicílio - Inocorrência - Crime permanente, de consumação prolongada no tempo - Presença da situação flagrancial que prescinde de autorização judicial - Depoimentos de policiais no sentido da existência de autorização de ingresso na residência do apelante - Ausência da aventada nulidade - Preliminar rejeitada. Pretendida absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - (...) Recursos desprovidos”. (TJSP; Apelação Criminal 1501519-49.2021.8.26.0567; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/07/2022; Data de Registro: 12/07/2022) (Sublinhado meu).

Superada a preliminar, no mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 e 05/06); boletim de ocorrência (fls. 20/24); auto de exibição e apreensão (fls. 14/15); laudo de constatação provisória (fls. 28/30); laudo químico toxicológico definitivo (fls. 80/82), com resultados positivos para "cocaina", substância presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações; laudo das munições (fls. 140/141), que atestou o potencial lesivo delas; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

A prova de autoria também é segura. A começar pela própria confissão do acusado. Senão vejamos.

Em seu interrogatório, José Luiz declarou que estava sentado na entrada de sua casa, sem nada consigo, porém, ainda assim, foi abordado e levado para interior do seu imóvel. Disse que os agentes da lei revistaram a residência, encontrando a mochila, contendo os ilícitos apreendidos nos autos. Afirmou que recebeu tal objeto naquele mesmo dia, de um conhecido do bairro, que prometeu pagar-lhe cento e cinquenta reais para guarda-la por três dias. O interrogando negou que conhecesse os policiais militares que o prenderam, esclarecendo que as munições eram herança de seu pai, ex- policial militar. Por fim, alegou ter sido agredido pelos policiais militares que lhe questionavam sobre a existência de arma de fogo em sua posse.

Destaco que o reconhecimento de culpa pelo acusado está em linha com o relato das testemunhas de acusação, conforme passo a expor.

O policial militar Silvio Alexandre de Freitas contou que durante patrulhamento de rotina, o réu, até então sentado na porta de sua casa, saiu correndo para o interior do imóvel localizado em frente ao local onde estava, ao ver a aproximação da viatura policial. Desconfiado, imediatamente saiu ao seu encalço, logrando detê-lo. Em revista, entorpecentes foram encontrados em sua posse. Disse que José Luiz confessou, de pronto, o tráfico, indicando o local onde guardava mais drogas, dinheiro, apetrechos utilizados no vil comércio e munições, no interior da casa. De acordo com a testemunha, o réu informou que receberia cento e cinquenta reais por semana para manter sob sua guarda tais ilícitos, de uma pessoa conhecida pelo vulgo de "Fortão". Questionado, afirmou não conhecer o réu até aquele dia, e que todo o material estava junto, no interior de uma bolsa.

Seu companheiro de farda, André Luiz de Jesus da Silva fez coro às suas declarações.

Já a testemunha Nadir Ledoína de Sales Hilário disse que estava na porta de sua casa, presenciando quando os agentes estatais chegaram e abordaram o réu, que estava sentado na porta de sua casa falando ao celular. Afirmou que não visualizou a apreensão dos entorpecentes. Informou ser vizinha de frente do réu, e que este morava sozinho no imóvel. Ao final, contou que o acusado não tentou correr para dentro do imóvel, sendo abordado na porta da casa, enquanto estava sentado.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a confissão do réu se encontra alinhada com as demais provas do processo.

Sabe-se que a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pelo increpado, fornece elemento seguríssimo de prova, notadamente quando amparada por outros elementos de convicção, tal como no presente caso.

A propósito, em recente julgado:

"Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – (...) Consistentes relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu – Confissão judicial do réu – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Condenação mantida – (...) – Recurso de apelação parcialmente provido, sem reflexo na pena final". (TJSP; Apelação Criminal 1503582-66.2021.8.26.0302; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022) (Ênfase na reprodução).

Registre-se aqui, a ampla credibilidade que detém as palavras de policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública.

Neste sentido, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça deste estado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim é, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas também por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressaltado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade; poucas são as pessoas que se dispõe a

testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade do testemunho de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Como se viu, os agentes da lei foram enfáticos ao dizerem que o réu, desconhecido por eles até aquele dia, tentou correr ao perceber a aproximação da viatura policial.

De outro lado, convém destacar que a testemunha Nadir, arrolada pela defesa, por sua vez, já conhecia o réu antes dos fatos, por ser sua vizinha. Assim, suas palavras devem ser recebidas com reservas.

Afinal, como os agentes estatais saberiam que o réu, sem antecedentes criminais, e sequer conhecido por eles até o dia dos fatos, guardava grande quantidade de entorpecentes e munições?

Por fim, ainda com relação ao crime de tráfico, esclareço ser desnecessário para sua configuração que o agente seja flagrado em atos de mercancia, já que a prática de qualquer das múltiplas ações previstas no tipo penal se mostra suficiente para tal fim, sendo a finalidade mercantil demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos presentes autos, à luz da quantidade de entorpecentes e apetrechos

comumente utilizados para a venda no varejo (balança de precisão e microtubos, do tipo eppendorf, vazios).

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Assim, imperiosa a condenação do acusado pelo delito de tráfico.

O mesmo se diga em relação à imputação remanescente.

Como se sabe, a exigência legal de regularização de armamentos não é mera burocracia estatal, é garantia para a própria população que somente pessoas treinadas e psicologicamente preparadas portem ou possuam armas de fogo, munições e/ou acessórios.

Esclareço, outrossim, que o crime de posse ilegal de munições é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - Hipótese na qual a decisão impugnada se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição. (...). Agravo regimental desprovido”. (STJ. AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Irrelevante investigar o modo de aquisição das munições pelo acusado, na medida em que a ilegalidade da posse destas decorre da falta de registro, autorização ou permissão, de ampla divulgação, já que as munições deveriam ser entregues à polícia, não se podendo converter em uma conduta lícita, a ausência de registro, ou permissão, pelo modo de aquisição dos artefatos (herança, segundo o réu).

Como se viu, de acordo com suas próprias declarações, José Luiz tinha plena ciência da posse das munições e, ainda assim, optou por mantê-las ilegalmente em sua casa.

Frise-se que o laudo pericial acostado aos autos atestou que as munições foram percutidas, detonadas e deflagradas nos testes, de modo a comprovar eficazmente o potencial lesivo delas (fls. 140/141).

Refuta-se, outrossim, a aplicação do princípio da insignificância ao caso, a despeito da quantidade de munições apreendida, desacompanhadas de arma de fogo.

Considerando os bens jurídicos tutelados pelo referido tipo penal (segurança pública e a paz social), forçoso concluir que o porte ou posse de munições, artefatos estes que poderiam ser detonados de várias formas (colocados no fogo, atingida a espoleta com um prego etc.), gera um rebaixamento no nível de segurança pública, a merecer a proteção penal.

Ademais, de acordo com o próprio acusado, este guardava outros ilícitos para terceiro que, possivelmente possuía arma de fogo e utilizava-se justamente dessa estratégia (guardar arma de fogo e munições separadamente), para dificultar a apreensão pela polícia.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" (AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" (AgInt noResp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DAFONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no HC n. 626.888/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Posição também adotada pelo nosso Tribunal de Justiça:

"1-) Apelações criminais. Recepção dolosa e posse irregular de acessórios e munições. (...) 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. (...). 3-) O crime de posse irregular de acessórios e munições é de "perigo abstrato", não se exigindo qualquer resultado naturalístico para a sua consumação. Tanto isso é verdade que o legislador pune com sanção a posse da arma, acessório ou munição, independentemente de o armamento estar desmuniado ou a munição e acessório desacompanhados de arma de fogo. 4-) Incabível a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de considerável quantidade de munições apreendidas (...), circunstâncias suficientes para demonstrar a lesividade da conduta. (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1503770-40.2021.8.26.0664; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 13/09/2022; Data de Registro: 13/09/2022).

Logo, o delito em questão configura-se com a simples vontade livre e consciente de possuir arma de fogo, munição ou acessórios sem a devida autorização legal, o que ficou evidente no presente caso, ante a confissão do acusado e do depoimento das testemunhas de acusação.

Contudo, ao contrário da pretensão ministerial, entendo que a hipótese dos autos encerra crime único, malgrado a diversidade de tipos das munições (umas de uso permitido, e outras de uso restrito), por conta da unicidade do contexto fático, preponderando o crime mais grave (artigo 16, caput, da Lei 10.826/03).

Neste sentido:

"POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO - crime único - materialidade - auto de apreensão, laudos atestando a

eficácia da arma e das munições quanto à potencialidade lesiva e a ausência de documentação legalmente exigida comprovam a materialidade delitiva - tipicidade configurada - preponderância das munições de uso restrito sobre a arma e as munições de uso permitido - provimento para este fim. (...) - improvimento ao apelo". (TJSP; Apelação Criminal 1501372-89.2021.8.26.0545; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Atibaia - 1ª Vara Criminal Infância e Juventude; Data do Julgamento: 12/09/2022; Data de Registro: 12/09/2022) (Original sem marcações).

Portanto, é o caso de condenação do réu também pelo delito do artigo 16, caput, da Lei 10.826/03.

Passo às penas.

a) Crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

O réu é primário e de bons antecedentes (fls. 32/33 e 34). Contudo, há que se destacar a maior reprovabilidade da conduta censurada. Afinal, trata-se de 616,02 gramas de "cocaína" (massa líquida), distribuídas em 924 microtubos do tipo eppendorf, o que demonstra que a ação em tela atingiria diversos usuários lorenenses e/ou moradores de cidades vizinhas, que lutam contra o vício maligno.

Assim, deixar de valorar negativamente tal circunstância significaria negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatura constitucional, por equipar a conduta àquelas envolvendo pequena quantidade de narcóticos.

Portanto, à luz de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 1/4 (um quarto) acima do piso legal, ou seja, em 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes. Por outro lado, presente a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal). Logo, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, aqui em definitivo, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

O réu não faz jus à redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, na medida em que as minúcias do caso concreto revelam sua profunda intimidade com o narcotráfico, a despeito de sua condição de primário e de bons antecedentes aos olhos da lei.

Afinal, o acusado não comprovou a realização de ofício legítimo para seu sustento, nem mesmo informal e eventual.

Além disso, o réu está sendo condenado igualmente pelo porte de munições, sem contar os mais variados apetrechos comumente utilizados para o preparo de drogas encontrados em sua casa (pinos plásticos, do tipo eppendorf, vazios, balança de precisão).

Como se não bastasse, o próprio volume de drogas reforça a conclusão acima exarada, já que traficante algum confiaria a um neófito tamanha quantidade de narcóticos (mais de 900 pinos plásticos, contendo "cocaína").

Neste sentido, trago à colação, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). 1. Na hipótese dos autos, a causa especial de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 foi afastada não somente pela quantidade de drogas apreendidas - 17kg de maconha -, mas, também, em virtude da existência de outros elementos fáticos, notadamente a



apreensão de balança de precisão e outros apetrechos para a prática da traficância. (...) 2. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Agravamento regimental desprovido. (AgRg no HC 707.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) (Sublinhei).

Tais circunstâncias, portanto, estão a indicar que o réu é pessoa que vem trilhando o caminho do mundo do crime, dedicando-se às atividades criminosas, situação que afasta a incidência dessa causa de diminuição de pena, visto que não existe prova direta dessa circunstância, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, em julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENHIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitativa. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada. (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

É entendimento deste Julgador, que a redutora em questão se destina apenas aquele

que age por um impulso, em situação isolada, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico cuidou somente de um desvio em sua vida, o que não é o caso destes autos.

Registro, por fim, que tal entendimento encontra-se em linha, ainda, com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já que a quantidade de droga apreendida não foi o único elemento a ensejar a não aplicação do § 4º, do artigo em assunto, não se podendo cogitar no proibido bis in idem.

Nesse sentido:

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença”. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021) (Sublinhado meu).

b) Crime do artigo 16, caput, da Lei 10.826/03:

Tal como exposto anteriormente, o réu não possui maus antecedentes. No mais, anoto que as demais circunstâncias não lhe são desfavoráveis.

Assim, estabeleço a pena-base no piso, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária, verifico a incidência da atenuante da confissão espontânea, contudo não haverá reflexo nas penas, vez que já estabelecidas no piso legal, conforme jurisprudência sumulada.

Na última fase, por não existirem outras causas modificadoras, torno as penas definitivas, como fixadas na primeira etapa da dosimetria.

Em se tratando de concurso material de delitos, as penas deverão ser somadas, resultando em um total de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, à luz do quantum de pena aplicada. Pelas mesmas razões, inviável a aplicação de medidas despenalizadoras.

Ademais, tratando-se de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com valor total a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal; por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar JOSÉ LUIZ LUCIANO, qualificado nos autos, por violação aos tipos penais previstos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, e 16, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, a uma pena total de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, diária mínima, absolvendo-o da imputação referente ao delito do artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 386, III, do CPP.

Nego o apelo em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentava sua prisão preventiva se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Ademais, a pena relativamente alta que lhe foi imposta, assim como o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena, confere risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido.

Tráfico de Drogas - (...) - Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, no entanto, expeça-se a guia de execução provisória.

Custas pelo vencido.

Confira-se:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Apelo defensivo pelo abrandamento punitivo, por meio da mitigação das penas iniciais; do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; do deferimento do redutor da forma "privilegiada"; da atenuação do regime inicial; da revogação da prisão preventiva; e da gratuidade judiciária. (...). - (vi) Gratuidade judiciária. Benefício não concedido. Medida destinada, por excelência, a assegurar o acesso à Justiça. Réu que não logrou comprovar a hipossuficiência material. Assistência por defensores constituídos. Não incidência da presunção relativa de precariedade econômica. Pleitos afastados, com confirmação das penas. Negado provimento, na parte conhecida". (TJSP; Apelação Criminal 1500802-96.2019.8.26.0279; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itararé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021) (Sublinhado meu).

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder a sua destruição. Considerando que as munições apreendidas foram usadas e descartadas para confecção do laudo pericial, nada a apreciar com relação a elas.

Decreto o perdimento da quantia apreendida em favor da União, forte no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06. Expeça-se o necessário com o trânsito em julgado.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de DROGAS - Preliminar - Restituição de valor apreendido - Desacolhimento - Caderno processual que indica que o numerário questionado é proveniente da prática do tráfico de drogas - Inexistência de prova segura acerca da origem lícita do dinheiro apreendido - Perda em favor da união corretamente determinada - Inteligência dos arts. 62 e 63 da Lei n.º 11.343/06 - Preliminar rejeitada. (...) Condenação mantida. (...) - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1500220-88.2021.8.26.0356; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mirandópolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/11/2021; Data de Registro: 08/11/2021) (Ênfase minha).

Com relação ao celular igualmente apreendido, como nada fora produzido nos autos indicando o emprego dele no crime aqui sub judice, ou mesmo de que era produto do mesmo ou de qualquer outro delito, intime-se a quem de direito, que deverá apresentar prova idônea de sua propriedade, para retirá-lo. Não sendo tal aparelho reclamado, no prazo e nos termos do § 6º, do artigo 63, da Lei 11.343/06, deverão ser revertidos ao Funad; salvo se não apresentar mais conteúdo econômico. Nesse caso, após a devida certificação nos autos, fica autorizada a destruição, observadas as disposições normativas pertinentes.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal

Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.343/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA